

1517549-75.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212277/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 26565662 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2212277 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO GENTIL GIMENES

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517549-75.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517549-75.2022.8.26.0228 PD 992/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212277/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 26565662 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2212277 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO GENTIL GIMENES

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 25 de agosto de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, o senhor Porteiro dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, presente o réu Claudio Gentil Gimenez, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-

se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." Em seguida, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, após, foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu CLAUDIO GENTIL GIMENES foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia 04 de agosto de 2022, na Rua Arenito, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 233 porções de cocaína e 174 porções de crack, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo de constatação de fls. 23/26. Após o recebimento da denúncia (fls. 85/87), o réu foi devidamente citado (fl.) e ofereceu defesa prévia. Foi designada audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, B.O de fls.27/30, auto de exibição e apreensão de fls. 17, bem como pelo laudo de constatação de fls. 23/26 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls., que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, ao ser interrogado, o denunciado permaneceu silente (fls. 04). Em juízo, confessou os fatos. Ouvida na fase inquisitiva o policial HERMES narrou que estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas e, ao adentrarem na Rua Arenito, avistaram um desconhecido em movimentação suspeita sendo que este ao visualizar o depoente e seu parceiro entrou correndo pelas vielas mas conseguiram detê-lo em seguida, sendo que houve certa resistência a prisão, sendo algemado (fls. 02). No mesmo sentido, o depoimento do policial JONATHAN a fls. 03. Em juízo, o policial Jonathan confirmou o depoimento da fase policial. O policial Hermes em juízo também confirmou o depoimento da fase inquisitorial. O depoimento dos policiais, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão, quantidade e variedade de drogas evidencia que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se que o fato de as testemunhas serem policiais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles prestados. Inicialmente, cumpre observar que as testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem policiais é, a bem da verdade, atribuir-lhes indiretamente a pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso. A bem da verdade os que sustentam o teratológico "recebimento com ressalvas" do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho. Não se pode compactuar com tal forma de pensar, mormente se considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se

falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: "O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos" (TJSP - AC 205162-3/4 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT733/566).

Desta forma, restou evidente que a acusação se incumbiu de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento. No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de drogas. Já na segunda fase, observo que não há agravante nem atenuante, apenas a causa de diminuição, do § 4º do art. 33 da lei de drogas. Da imprescindibilidade do regime inicial fechado Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de "graça, anistia e fiança", relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por "hediondos" - seja na sua forma tentada ou consumada -, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida humana, tida esta pela Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais. Como se não bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da mercancia de entorpecentes, conseguem ainda "lavar" o dinheiro obtido, depositando-o na conta de "laranjas" fielmente associados às referidas organizações criminosas. Ademais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário, que se vê ruir aos poucos em torno da pessoa viciada, que muitas vezes dissecar todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido, no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado, que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), "a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado". Não há dubiedades, não há obscuridades, não há ambigüidades. O

dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena " Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, CLAUDIO GENTIL GIMENES, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais, apresentar alegações finais, da forma que segue. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos descritos na denúncia. O acusado foi notificado, citado, foi apresentada defesa prévia e a denúncia foi recebida. Durante a instrução probatória, foram inquiridos dois policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e o acusado foi interrogado ao final. Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. Em que pese a respeitável a manifestação ministerial, a ação penal é improcedente, como de passa a demonstrar. O policial militar JHONATHAN WERTON RODRIGUES DE LIMA declarou que foram averiguar disque denúncia de tráfico de entorpecentes. Avistaram o réu na via em posse de uma mochila, o réu empreendeu fuga, mas foi abordado; dentro da mochila, havia parte dos entorpecentes. Dentro da mochila, os entorpecentes estavam embalados como que para abastecer o ponto, e não para venda. Questionaram, o réu confirmou que as drogas eram para abastecimento. Cerca de 70% do material apreendido estava na mochila, 30% restante foi encontrada em local escondido próximo a onde ele foi detido junto com o dinheiro. Os policiais encontraram parte do material e dinheiro no local para onde o réu tinha ido, um beco sem saída. Provavelmente o réu dispensou uma quantidade de droga. A mochila não deu tempo de dispensar. O réu disse que estava desempregado e que usou o tráfico para conseguir dinheiro, mas que tinha feito poucas vezes. Foi a primeira vez que abordou o réu. A denúncia dizia o local do ponto de vendas de droga. O réu foi avistado sozinho em trajes de treinamento de atividade física. O policial militar HERMES FERREIRA DE SOUZA corroborou a versão de seu colega de farda, aduzindo que de pronto o réu confessou que estava fazendo abastecimento do local. CLAUDIO GENTIL GIMENES, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que tem duas filhas, uma de quatro meses e uma de cinco anos; estava devendo dois aluguéis. Um amigo ofereceu para levar uma bolsa para o "Mangue". Estava de bicicleta. Passou do beco, andou cerca de 2 metros e o rapaz gritou que a polícia tinha chegado. Não dispensou droga porque estava de bicicleta. Foi abordado pela polícia; eles perguntaram o que tinha na bolsa, jogou a bolsa no chão e os policiais abriram; ficou com medo, correu e estava vindo outra viatura. Sabia que na mochila transportava droga. Assim, o conjunto probatório não indica certeza da autoria do delito. A confissão não é rainha das provas. Trata-se, portanto, de um caso no qual repousam sérias dúvidas acerca da configuração delitiva. Não há provas cabais de autoria delitiva, capazes de afastar a versão do acusado. De tudo quanto exposto, se depreende que, ao menos, resta dúvida fundada, que deve ser interpretada em favor do réu, por imposição do estado constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII). A incerteza não compactua com o juízo normativo exigido para a condenação. Pelo exposto, requer seja o acusado ABSOLVIDO, com fundamento no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal. Caso, diante de todas as provas contrárias, se entenda pela condenação requer sejam recebidos os seguintes pedidos. Requer seja a pena base fixada no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59 Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, requer-se a aplicação da atenuante da confissão, superando o entendimento da Súmula n. 231 do STJ em virtude do princípio da individualização da pena. Requer ainda a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo (2/3), tendo em vista que o acusado é primário, tem bons antecedentes e que não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Requer seja fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, "c" do Código Penal, eis que presentes todos os seus requisitos. Deve-se ter

por claro que o Pretório Excelso pacificou entendimento em seu Pleno de que é inconstitucional a previsão de obrigatoriedade de regime inicial fechado da Lei dos Crimes Hediondos (art. 1º, §1º), no HC 111.840/ES. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal e na Resolução nº 5/12 do Senado Federal. Por fim, finda a instrução criminal e ausentes as hipóteses ensejadoras da constrição cautelar, requer o direito de apelar de eventual sentença condenatória em liberdade." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. CLAUDIO GENTIL GIMENES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque em 04 de agosto de 2022, na Rua Arenito, nesta Comarca de São Paulo, trazia consigo/guardava, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 233 porções de cocaína e 174 porções de crack, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma oportunidade foi apreendido o valor de R\$ 235,00 relacionado com o tráfico de drogas. O réu foi preso em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 85/87), o réu foi citado (fls. 130), sendo apresentada resposta à acusação no termo de audiência. Durante a instrução criminal foram ouvidos os PMS responsáveis pela prisão do acusado e este foi ao final interrogado. Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP e as partes debateram oralmente. O Ministério Público, em sede de debates orais, pediu a condenação. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição. Subsidiariamente requereu: a pena mínima, considerada a atenuante da confissão e o redutor do tráfico privilegiado; a aplicação dos substitutivos penais do art. 44 do CP; e o regime prisional aberto. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminoso e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/17; pelo Laudo de Constatação de fls. 23/26; pelo L.E.Q.T. de fls. 120/122; pelos depoimentos dos PMS nas duas fases procedimentais; pelo depósito judicial do numerário apreendido (fls. 52); e pelo teor da confissão do acusado ao ser interrogado em Juízo. Ouvidos por ocasião do A.P.F.D. e nesta data sob o crivo do contraditório, os PMS que detiveram o acusado esclareceram que realizavam patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visando justamente coibir o ilícito. Pelo local avistaram o réu CLAUDIO na "biqueira". Assim que o acusado visualizou a viatura, ele empreendeu fuga e seguiram no encalço do mesmo. Durante a fuga CLAUDIO dispensou a quantia de R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em notas e moedas diversas e 70 (setenta) porções de cocaína. Feita a abordagem de CLAUDIO, houve a revista pessoal, sendo localizada na mochila que o réu portava, mais 163 (cento e sessenta e três) porções de cocaína e 174 (cento e setenta e quatro) porções de crack. Interrogado em Juízo, o réu admitiu que aceitou fazer o transporte de drogas, para abastecimento da "biqueira". Assim agiu por estar desempregado, com aluguéis em atraso e com família para prover. No ponto de venda de drogas foi abordado pelos PMS que de fato localizaram as drogas na mochila que portava. Também foi apreendido dinheiro. Enfim, o contexto probante, corroborou a imputação descrita na inicial. Neste mesmo sentido a variedade, a quantidade e a forma de embalagem das substâncias entorpecentes, assim como o numerário encontrado com o acusado. Uma vez demonstrada a narco-traficância, mister se faz a formalização do decreto condenatório e a fixação da pena correspondente. Na fase do artigo 59 do Código Penal, dada a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, destinadas justamente ao abastecimento da "biqueira", fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria de pena, em vista da atenuante da confissão espontânea, diminuo a sanção ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por não ter ficado comprovado que o réu integrasse diretamente organização criminoso, há possibilidade de tratamento punitivo mais benéfico, com a aplicação do disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. Assim, reduzo a pena supra em 2/3 (dois terços), o que perfaz, em definitivo, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Isto posto, CONDENO o réu CLAUDIO GENTIL GIMENES, RG 43.609.726 e CPF 434.788.018-93, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e

sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao deferir a ordem, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Por conta disso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada no Juízo das Execuções, nos termos do artigo 46 do Código Penal. Na hipótese de descumprimento das condições impostas o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Diante da concessão da pena restritiva de direito, expeça-se em favor do sentenciado alvará de soltura clausulado. Oficie-se ao E. TJSP, em informações complementares às anteriormente prestadas no H.C. de fls. 59/82, comunicando a perda de objeto do "writ", por conta da expedição de alvará de soltura na presente data. O valor em dinheiro arrecadado com o réu (cf. fls. 52) deverá ser revertido em favor da SENAD. A droga deverá ser incinerada. Demais bens apreendidos devem ser encaminhados para destruição. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais." Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Mauricio), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA